

1500964-79.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... voto recente da 6ª Turma:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME FECHADO. NATUREZA E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. 1. Consoante entendimento desta Corte, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500964-79.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500964-79.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2115008/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 17586271 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 964/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2115008 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2115008 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 964/21/638 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RAFAEL SOUZA DE MORAIS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

RAFAEL SOUZA DE MORAES e ORLANDO APARECIDO DA LUZ DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública e devidamente processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal; e no artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, todos em concurso material, porque no dia 27 de abril de 2021, por volta das 22h50min, na Rua José Antônio de Melo, defronte ao nº 50, da via pública, Jundiapéba, nas proximidades de escola, hospital e unidade militar, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, RAFAEL SOUZA DE MORAES, trazia consigo, para

fornecimentos a terceiros, aproximadamente, cerca de 2,230kg (dois quilogramas e duzentos e trinta gramas) da droga Cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, agindo em concurso e devidamente associado com ORLANDO APARECIDO DA LUZ DOS SANTOS, que concorreu de qualquer modo para que RAFAEL SOUZA DE MORAIS, trouxesse com ele, as reportadas drogas.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ORLANDO APARECIDO DA LUZ DOS SANTOS e RAFAEL SOUZA DE MORAIS, qualificados nos autos, em concurso e unidade de desígnios, devidamente associados, guardavam, para fornecimentos a terceiros, aproximadamente, cerca de (i) 974,29g (novecentos e setenta e quatro gramas e vinte e nove centigramas) da droga cocaína, e (ii) 93,350kg (noventa e três quilogramas e trezentos e cinquenta gramas) da droga Cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 16 de junho de 2021 (fls. 205). Houve aditamento em 16 de junho de 2021 (fls.250).

Notificados (fls. 172, 175, 317 e 320), depois citados (fls. 330 e 331), os denunciados apresentaram defesa prévia (fls. 178/183 e 198/199), e resposta à acusação (fls. 312/314 e 367).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 337).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas e interrogatórios dos réus (fls. 423 e 433).

Ao final, em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e a condenação dos réus (fls. 436/445).

A Defesa de Orlando alegou nulidade pela ilicitude de provas e a absolvição, e, subsidiariamente, a atenuante da menoridade relativa, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (fls. 449/463). E a Defesa de Rafael alegou inépcia da ação e, requereu a absolvição, e, subsidiariamente, a atenuante da confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento de pena, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a detração penal, a revogação da prisão e o afastamento da pena de multa (fls. 466/491).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente aponto a legalidade do flagrante.

O Código de Processo Penal autoriza a busca domiciliar para "descobrir objetos necessários à prova de infração" quando presentes "fundadas razões". O inciso XI do art. 5º institui como garantia fundamental a inviolabilidade de domicílio traçando seus limites: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)". Desta forma, a expressão legal "fundadas razões" deve ser restrita a hipóteses de flagrante delito em razão da proteção constitucional.

O STF, responsável pela uniformização da interpretação constitucional, fixou no Tema 280 de sua Repercussão Geral (RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016) a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

No âmbito do STJ, responsável pela uniformização da interpretação do direito infraconstitucional, há diversos julgados a respeito do tema, entre os quais destaco voto recente da 6ª Turma:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO.

FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.

MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.

REGIME FECHADO. NATUREZA E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENHIDOS. 1. Consoante entendimento desta Corte, "nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protraí no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si

só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito" (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.) 2. As instâncias ordinárias concluíram que os agentes públicos (policiais) tinham fundadas suspeitas da prática de crime na casa do acusado, tendo em vista que, ao avistar os policiais, dispensou na rua uma sacola contendo diversos eppendorfs de cocaína (63gr), evadindo-se para o interior de sua residência. 2. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do acusado evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso no imóvel em que se residia o paciente, não se constatando, portanto, ilicitude das provas obtidas. 3. O indeferimento da minorante do tráfico se deu não apenas diante da natureza e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (na mochila, 63,0g de cocaína distribuídos em 314 eppendorfs; e, dentro da residência, mais 255,0g de cocaína, uma balança de precisão, um liquidificador com resquícios de droga, R\$128,00 em espécie e uma arma de fogo municada), mas também pelas circunstâncias do fato, diante das informações de que o paciente é "gerente do tráfico" local. 4. Quanto ao regime de cumprimento de pena imposto, a natureza e a quantidade dos entorpecentes encontrados justificam a imposição do regime prisional mais severo, sem que tal medida constitua constrangimento ilegal. 5. Habeas corpus denegado. (HC 683.211/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

No caso em tela, assim que detido com drogas, o réu Rafael de pronto indicou a residência do acusado Orlando, onde estavam armazenadas o restante das drogas. Assim, a diligência mostrou-se legítima porque os policiais tinham em mãos um flagrante de tráfico a partir da busca pessoal, esta feita com observância dos critérios inscritos no §2º do art. 240 e art. 244 do Código de Processo Penal. Isso porque havia fundada suspeita, em razão do local e horário em que se encontravam. Nesse sentido:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar. Crime permanente indicando situação de flagrância apta a autorizar a pronta ação da Polícia, independentemente de mandado, sem se desprezar o fato de o réu haver franqueado o acesso dos policiais ao imóvel. Inteligência dos artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal. Nulidade inexistente. Matéria rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada pelos relatos seguros e coesos de policiais militares, que apreenderam 68 tijolos de maconha na residência do réu. Condenação mantida. Pena-base acima do piso em face de circunstância desfavorável representada pela grande quantidade do entorpecente apreendido, consoante artigo 42 da Lei nº. 11.343/06. Atenuante da confissão espontânea colidente com a prisão em flagrante, consoante jurisprudência da SUPREMA CORTE, lamentada a inércia da Justiça Pública a impedir a revisão do julgado nesta parte. Quadro adverso colidente com o privilégio descrito no artigo 33, § 4º, daquela mesma Lei Extravagante e com a substituição da corporal por restritivas de direitos também incabível diante do montante da reprimenda. Regime inicial fechado único adequado ao crime de natureza hedionda, sem se ignorar o quadro adverso também inconciliável com retiro menos severo. Provimento tão-só ao apelo da acusação (Apelação Criminal nº // 1503215-65.2020.8.26.0047, Rel. Farto Salles, 6ª Câmara de Direito Criminal, j.18/11/2021). Afasto, ainda, a preliminar de inépcia da denúncia, eis que a conduta de cada um dos acusados foi detalhadamente descrita, permitindo o exercício da ampla defesa. Passo à análise do mérito.

Processe o pedido contido na denúncia.

A materialidade dos delitos está configurada pelos autos de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 11/19, auto de exibição/apreensão de fls. 22/24, pelo laudo de constatação de fls. 26/31, exame químico-toxicológico de fls. 146/149, e laudos do Instituto de Criminalística de fls. 206/209, 210/218, 219/234 e 235/247, bem como pela prova oral colhida. Também, a autoria criminosa dos acusados evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Em Juízo, Ladislau de Souza Martins, Policial Militar, declarou que estavam em patrulhamento por Jundiapéba e localizaram um veículo, produto de furto. Colocaram a viatura próxima, porque queriam observar para ver se logravam localizar quem havia subtraído o veículo. Solicitaram o apoio de outra viatura de força tática, e no período em que estavam conversando, depararam-se com um veículo Siena, chegando na via, parou na Rua José Antônio de Melo, onde desceu o acusado Rafael. Aproximaram-se do veículo e começaram a observar a residência em que o acusado havia entrado. Rafael saiu com uma sacola na mão, em seguida, foi feita a abordagem. O acusado afirmou de pronto que estava de posse de drogas, e que havia mais drogas na residência. Saíram mais dois indivíduos da residência, ao observarem os policiais, adentraram correndo para dentro da casa, e foram abordados pelos policiais. O acusado Orlando foi identificado como dono da residência, e Igor, amigo dele. O acusado Orlando declarou que havia mais drogas, embaixo do berço. Na busca pessoal, nada foi localizado de ilícito. No local, foram localizadas as drogas, dinheiro, anotações e telefone celular. O outro indivíduo, não tinha conhecimento das drogas. Não conhecia nenhum acusado. O acusado Rafael ia abastecer um ponto no Santo Ângelo, próximo às "Torres". Não tinha conhecimento de que havia drogas.

Na mesma toada, Willian Ricardo Candido de Oliveira, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento por Jundiapéba, localizaram um veículo, produto de furto. Estacionaram a viatura e solicitaram apoio, enquanto conversavam, chegou um veículo, Siena, que parou em frente a uma residência, e desceu um indivíduo. O indivíduo adentrou a residência e o carro seguiu a via, retornou e parou em frente à casa novamente, ligou o pisca-alerta, o que gerou suspeita. O indivíduo saiu com uma sacola branca nas mãos. Indagado, confessou que na sacola, havia drogas e dentro da casa, havia mais. Saíram mais dois indivíduos da casa, ao avistarem os policiais, evadiram-se. Foram abordados e o acusado Orlando, disse que era dono da residência, apontou onde estavam as drogas. Em busca, encontraram as drogas embaixo do berço, com anotações, dinheiro e telefone celular. O acusado Orlando, declarou que o outro indivíduo, era um amigo. O acusado Rafael disse que iria abastecer uma "biqueira". Orlando afirmou que a droga era dele.

José Sebastião de Moraes, motorista de aplicativo, disse que atendeu uma chamada no Conjunto Santo Ângelo, pegou o passageiro e o levou em Jundiapéba, em uma rua de terra. Não conhecia o passageiro. Explica que o passageiro tem direito à parada. Já era de noite, o acusado pediu para parar, parou, ele desceu, e como era de noite, acendeu o pisca-alerta para ajudar na iluminação, para fazer a manobra e parar em frente à residência. Quando o acusado voltou, estava com uma sacolinha na mão, entrou no carro de novo, ao entrar, a polícia veio e deu voz de prisão. Não viu o que havia na sacola. Entrou com ele na casa, saíram várias caixas de dentro. Não ouviu nenhuma conversa e não viu o que havia no interior das caixas. Disse que antes dos policiais terem dado voz de prisão, questionaram o que tinha dentro da sacola, contou o que tinha e que dentro da casa, tinha mais. Não viu mais ninguém saindo da casa.

A testemunha de defesa, Wesley de Brito Barreto, narrou que conhece o acusado Orlando, trabalha com lava-rápido, ganha em torno de R\$ 1.000,00 (mil reais). Não tinha conhecimento desses fatos, em relação a Orlando. Para ele, foi novidade. Na mesma toada, Ana Carolina, disse que vive no local há uns dois meses. O acusado Orlando, trabalha com lava-rápido, ganha por volta de R\$ 1.000,00 (mil reais). Estava guardando algo para alguém lá. Não sabia o que era, porque ele não falava. Ficou sabendo no dia do ocorrido, que era a droga maconha, não sabe a quantidade. Não sabe o quanto ele ganhava para guardar.

Igor Matheus Terra Nagali, em solo policial, narrou que "realmente estava no local dos fatos, na casa de seu amigo Orlando. A mulher de Orlando, chamou sua companheira, Kênia Camile, para irem a casa deles comerem pastel. Por volta de quase 22h de ontem (27/04), estavam todos dentro da casa de Orlando, quando ele recebeu uma ligação e, posteriormente, chegou uma pessoa. Orlando saiu da mesa, foi para fora da residência e depois retornou. Não viu o que Orlando foi fazer, só sabe que ele encontrou outra pessoa lá fora. Depois, Orlando retornou, novamente, para

fora da residência, visto que o cachorro estava latindo muito. Foi lá ver o que era, nesse momento, apareceram os policiais militares, os quais, foram entrando na casa, procurando drogas. Viu que Orlando confessou aos policiais que haviam drogas dentro da casa, inclusive, mostrou o lugar onde estavam guardadas. Viu que as drogas estavam em um dos quartos da casa. Não sabia que existiam drogas dentro da casa. Até sabia que Orlando estava envolvido no movimento de tráfico de drogas, mas não tinha ciência de que tinha drogas na casa dele. Atualmente, está trabalhando na Adega Grau, que fica na Rua José Pereira, Jundiapéba, nesta cidade”.

Os acusados foram ouvidos em juízo.

Rafael Souza de Moraes, declarou que recebia cerca de R\$ 300,00 (trezentos reais) para guardar drogas na residência e transportá-la para o Conjunto Santo Ângelo. Recebia o dinheiro de pessoa que não se identificou, mas não se confunde com o corréu. É a primeira vez que pratica os fatos narrados e que guardava drogas há cerca de uma semana. A residência que guardava as drogas, ficava em frente à casa de Orlando. O aluguel da residência era pago por Fernando, ninguém morava na casa. Residia no Conjunto Santo Ângelo, ia até a residência para buscar as drogas e transportá-las. O corréu Orlando, apenas estava no local com o filho, quando os policiais chegaram e o pegaram. Não conhece Ana Carolina e não conhecia o corréu Orlando, o conheceu na viatura. Trabalha no transporte de drogas há uma semana. Conheceu Fernando, em uma balada, momento em que Fernando propôs a ele, a guarda das drogas. Somente guardava as drogas.

Orlando Aparecido da Luz dos Santos, disse que estava na residência com a esposa e filho. Quando ouviu latidos de cachorros, foi verificar o que estava acontecendo. De forma que, saiu da residência e notou um veículo com o pisca-alerta acionado, a porta do passageiro aberta e o motorista no interior do veículo. Em seguida, foi conversar com o motorista do veículo, mas foi abordado por policiais, tendo eles dito que o corréu Rafael, guardava drogas na residência. Foi levado ao interior da casa. Indagado, negou a prática dos fatos. Disse para não levarem a esposa e o filho à Delegacia de Polícia, apenas ele. Encontrou com o corréu Rafael, no interior da viatura, e foram levados à Delegacia. Não conhecia os policiais de data anterior. Reside no mesmo terreno da residência do corréu Rafael, onde as drogas estavam. Ana Carolina é esposa dele e faltou com a verdade quando foi ouvida em Juízo. Não conhece Igor ou Fernando.

Essas são as provas coligidas aos autos. E, pelo demonstrado, os réus, associados, dedicavam-se à mercancia ilícita.

As declarações dos policiais militares, bem como do motorista do aplicativo, José Sebastião, são uníssonas em apontar os réus como autores dos delitos praticados. O acusado Rafael trazia na sacola 2,230 kg de maconha, enquanto Orlando concorria para a conduta criminoso. Certo, ainda, que os réus acordaram de guardar os entorpecentes na residência de Orlando.

Não obstante a negativa do réu Orlando, sua esposa, Ana Carolina, ouvida sob o crivo do contraditório, afirmou que Orlando estava guardando algo para alguém lá. Não sabia o que era, porque ele não falava. Ficou sabendo no dia do ocorrido, que era a droga maconha, não sabe a quantidade.

Nota-se que, não houve nenhuma contradição entre os depoimentos das testemunhas policiais, nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e claros.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ – AC. – Rel. Synésio de Aquino – RDTJRJ 7/287).

Aponto ainda as anotações constantes do caderno apreendido na residência do acusado Orlando, periciado às fls.220/234. A partir de fl.227 verifica-se a contabilidade da mercancia, com a entrada e saída de drogas e dinheiro.

A associação criminoso entre os acusados para o trafico de entorpecentes é

evidente. Cabia ao réu Orlando a guarda da droga (em grande quantidade) e ao acusado Rafael sua distribuição aos pontos, conhecidos como 'biqueiras'. Os objetos apreendidos dão conta da divisão de tarefas: balança de precisão, celulares e caderno de contabilidade, tudo a indicar o liame para mercancia. A estabilidade é cristalina, eis que não se guarda grande quantidade de entorpecente para a realização de única conduta. Seria ilógico e contraproducente. A causa de aumento de prevista no inciso III, do artigo 40, da lei de Drogas também ficou plenamente comprovado pela localização da residência do acusado Orlando, demonstrada pelo laudo do local dos fatos às fls.206/209.

Por outro lado, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da lei de Drogas. Com efeito, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa.

(...) III - Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência

(precedentes). (...) Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 287.687/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)

(...) 4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.

(...). 5. Ordem denegada. (STJ, HC 127221, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015)

E, enquanto a primariedade e os bons antecedentes são fatores objetivos, apurados a partir da Folha de Antecedentes dos réus, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração de organização criminosa, por seu turno, são examinadas com base (i) na quantidade e/ou variedade e/ou nocividade da(s) droga(s) apreendida(s); (ii) na própria Folha de Antecedentes; (iii) no modo/forma de acondicionamento da(s) droga(s); (iv) no próprio modus operandi do tráfico de drogas; (v) na conduta social do(s) réu(s); (vi) nos instrumentos destinados ao tráfico de drogas (balança, anotações de contabilidade, armas, pinos, sacos para dosagem etc.) eventualmente apreendidos; (vii) no concurso eventual de agentes; (viii) na apreensão de expressiva quantidade de dinheiro associada à ausência de comprovação de atividade lícita ou apreensão de dinheiro em notas miúdas; (ix) no local da abordagem; (x) ausência de ocupação lícita. Conferir:

(...) A negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 por aquele Tribunal Regional Federal não está lastreada em presunções, ilações ou conjecturas. Pelo contrário, apresentou ele elementos concretos que apontam que a paciente se dedicava à atividade criminosa, ficando demonstrado que ela teria realizado outra viagem ao Brasil com idêntico propósito (transporte de drogas). Logo, qualquer conclusão em sentido contrário por parte da Suprema Corte demandaria o revolvimento de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal. (...). (STF, HC 128754, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 10-05-2016 PUBLIC 11-05-2016) Habeas corpus.

2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Impossibilidade. Condenação transitada em julgado pelo mesmo delito. Dedicação à atividade criminosa. 4. Regime inicial fechado estipulado exclusivamente em razão da previsão legal contida no art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, já declarado inconstitucional pelo STF. Pena-base fixada no patamar mínimo. Paciente primário (condenação intercorrente definitiva). Ausência de motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. 5. Decisão monocrática do STJ não impugnada por agravo

regimental. Concessão da ordem, de ofício, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. (STF, HC 130889, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 04-12-2015 PUBLIC 07-12-2015).

5. Não se constata ilegalidade flagrante na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão aplicada ao paciente, pois essa tem por base, como se verifica no acórdão da apelação, as condições subjetivas valoradas negativamente. 6. A quantidade de pena privativa de liberdade imposta ao paciente torna prejudicada, por si só, a pretendida substituição por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). 7. Habeas corpus denegado. (STF, HC 127241, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015)

(...) 2. Não há constrangimento ilegal no ponto em que foi negada a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com fundamento em elementos concretos que indicam a dedicação do paciente a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, consubstanciados na apreensão de razoável quantidade de maconha e de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas etc) e no registro de campanhas policiais, por vários dias, que constatarem grande movimentação de pessoas no local. 3. Ordem não conhecida. (STJ, HC 272.710/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

(...) 5. Concluído pela instância antecedente, com fulcro nos elementos colhidos na instrução e com base nas circunstâncias fáticas do delito (ausência de comprovação de atividade lícita associada ao fato de ter sido surpreendido com certa quantidade de droga - 1 pino de cocaína, pesando 0,58g, e 7 porções de maconha, pesando 7,25g, - e expressiva quantia de dinheiro - R\$ 1.636,00 - quando indicado como pessoa responsável pela venda de tóxicos no banheiro), que o paciente se dedicava ao tráfico de drogas, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. (...). (STJ, HC 357.934/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

(...) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada no caso concreto em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas, evidenciada sobretudo pelas circunstâncias do fato (ponto de venda de drogas, balança de precisão, várias pedras de crack, dinheiro em notas miúdas e 15 celulares), pelos depoimentos dos policiais carregados aos autos e pela quantidade de drogas apreendidas. Para se acolher a tese de que o paciente não se dedica a atividades criminosas, é necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus. - Incabível a substituição de pena privativa de liberdade superior a 4 anos por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 291.910/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 17/12/2015).

Ademais, a "(...) primariedade e os bons antecedentes não são suficientes ao deferimento do benefício, pois, nos termos do que contido no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a aplicação da redução da pena depende, ainda, de que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, (...)." (STF, HC 98366, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-022 DIVULG 04-02-2010 PUBLIC 05-02-2010 EMENT VOL-02388-01 PP-00192).

Nesse contexto, inaplicável a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), considerando: (i) a diversidade, nocividade e a quantidade dos entorpecentes; (ii) e a forma de acondicionamento (97,81 quilogramas de maconha e 974,29 gramas de cocaína), fatores que, em conjunto, demonstram dedicação a atividades criminosas. Aponto ainda que, com os réus, foram apreendidos os seguintes instrumentos: (iii) balança de precisão, 03 telefones celulares e anotações indicativas da contabilidade do tráfico. Ainda, cerca de R\$915,00, valor expressivo para quem não apresentou comprovação de atividade lícita.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade dos acusados quanto aos fatos descritos na exordial acusatória. A condenação é a medida que se impõe.

Passo ao cálculo da pena.

Réu Rafael Souza de Moraes

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal e ao artigo 42, da Lei Antidrogas, este preponderante àquele, verifico que, em poder dos acusados, foi apreendida grande quantidade de entorpecente: 97,81 quilogramas de maconha e 974,29 gramas de cocaína. Assim, a pena base dos artigos 33 e 35 serão aumentadas em 1/4, perfazendo, respectivamente, 06 anos e 03 meses de reclusão, e 625 dias-multa, e 03 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase, inaplicável a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da lei 11343/06, conforme fundamentação.

Contudo, comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da lei de Drogas, as penas são elevadas em 1/6, finalizando, para o artigo 33, em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa, e, para o artigo 35, em 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, e 1020 dias-multa.

Réu Orlando Aparecido da Luz dos Santos

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal e ao artigo 42, da Lei Antidrogas, este preponderante àquele, verifico que, em poder dos acusados, foi apreendida grande quantidade de entorpecente: 97,81 quilogramas de maconha e 974,29 gramas de cocaína. Assim, a pena base dos artigos 33 e 35 serão aumentadas em 1/4, perfazendo, respectivamente, 06 anos e 03 meses de reclusão, e 625 dias-multa, e 03 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, em visto do réu, no dia dos fatos, ser menor de 21 anos de idade, a pena, portanto, será diminuída de 1/6, perfazendo, para o artigo 33, em 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa, e para o artigo 35, em 03 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa.

Na terceira fase, inaplicável a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da lei 11343/06, conforme fundamentação.

Contudo, comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da lei de Drogas, a pena é elevada em 1/6, finalizando para o artigo 33, em 06 anos e 27 dias de reclusão, e 606 dias-multa, e para o artigo 35, em 03 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão, e 850 dias-multa.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica dos acusados, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, ideal para o prevenção e repressão do caso concreto.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo

em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus:

(i) RAFAEL SOUZA DE MORAIS, qualificado nos autos, como incurso no 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 35, caput, ambos c.c. o artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de, respectivamente, 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 729 dias-multa, e, 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 1020 dias-multa.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena total imposta será de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, e 1749 dias-multa, no mínimo legal.

(ii) ORLANDO APARECIDO DA LUZ DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 35, caput, ambos c.c. o artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de, respectivamente, de 06 anos e 27 dias de reclusão, em regime fechado, e 606 dias-multa, e de 03 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, e 850 dias-multa.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena total imposta será de 09 anos, 08 meses e 19 dias de reclusão, em regime fechado, e 1456 dias-multa, no mínimo legal.

Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de responderem ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-los após a sentença que os condenaram.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada as prisões cautelares dos acusados que devem ser mantidas pelas razões acima expostas.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Por fim, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei nº 11.343/06 (fls. 22/24).

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra - CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls. 22/24).

Autorizo, desde já, a destruição dos demais objetos: sacolas, embalagens, balança digital, por inexpressividade econômica (fls. 22/24).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Transitada em julgado a presente sentença: a) intinem-se os condenados para pagamento das penas de multas, no prazo de 10 dias (artigo 50, caput, do Código Penal); b) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo para os fins do artigo 15, inciso II, da Constituição Federal; d) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA